

事长、法定代表人，通过线上、线下进行宣讲培训，发展会员，属于传销活动的组织者、领导者，是主犯，应当按照其所组织、指挥或者所参与的全部犯罪处罚。被告人谢某系传销组织的管理人员，担任生物科技公司的“副董事长”、地方团队队长等职务，除管理自己的团队外，还协助兼管了较多的公司事务，积极开拓市场、发展会员，对促进传销组织的发展和扩大起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥或者所参与的全部犯罪处罚。被告人王某负责公司的财务管理，其工作涉及公司大小事务，属于涉案公司重要的管理人员，是主犯，应当按照其所组织、指挥或者所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某在传销组织中承担部分财务、协调等职责，在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人廖某、许某在传销组织中承担推广宣传、培训等职责，担任地方团队队长、讲师，对会员上课、培训，宣传公司运营模式，对传销活动的扩大发展起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。

四、关于各被告人非法所得的认定

根据各被告人供述，各种收入、待遇、奖励等均是以虚拟货币的发放体现，或者由王某等人出售虚拟货币兑现后支付，但个人名下的虚拟货币是否出售、兑现，及如何使用等，在会计鉴定中没有明确。对于各被告人非法所得，法院结合各被告人供述、网络传销平台相关数据及银行交易明细，综合予以确认。其中，被告人王某炒A币获得人民币12万元、公司收的海南购房款40万元给其哥哥王某1、公司的钱18万元给其哥哥王某1和父亲王某2，合计个人非法所得为700000元；被告人谢某两次分红11847元、公司奖励黑色轿车一辆、卖A币变现17万元，合计个人非法所得为181847元及黑色轿车一辆；被告人廖某获得四次分红共1万元、卖A币获得22万元、讲师费28965元，合计个人非法所得为258965元；被告人许某非法所得为兑现A币250000元；被告人黄某将公司手机款449600元放在其姐黄某某处、兑现A币175万元用于归还个人债务，合计非法所得为2199600元。

被告人李某伙同谢某、王某、廖某、许某、黄某等人以经营活动为名，要求加入者缴纳相应等级数额的费用换取一定价值的数字货币获得加入资格，并

按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱加入者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人李某、谢某、王某起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥或者所参与的全部犯罪处罚。被告人廖某、许某、黄某起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李某、谢某、王某、廖某、许某、黄某到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可依法从轻处罚。被告人李某、谢某、王某、黄某配合公安机关将被扣押的虚拟货币转化为人民币或退缴部分非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人李某系盲人，可以从轻处罚。被告人李某、谢某、王某、廖某、许某、黄某当庭自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人廖某、许某在案发后退出全部非法所得，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，并经司法行政部门社区调查评估，建议适用社区矫正，可以宣告缓刑。综上所述，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40万元；

二、被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元；

三、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元；

四、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；

五、被告人廖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元；

六、被告人许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元；

七、被告人廖某退出的个人非法所得人民币258965元、被告人许某退出的非法所得人民币250000元，被告人黄某在公安机关退出的非法所得人民币

539600元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人谢某的个人违法所得人民币181847元、被告人王某的个人违法所得人民币700000元、被告人黄某的个人违法所得人民币1660000元，予以没收；

八、对涉案非法财物，被公安机关依法扣押的生物科技公司950台手机、公司所有李某名下的汽车一辆、谢某名下获得奖励的汽车一辆、李某虚拟货币9479926.4C币换算成人民币59973962.2元、谢某虚拟货币C币134571.71个换算成人民币913259元、王某的虚拟货币C币25389.74个换算成人民币172305元、黄某虚拟货币173994C币换算成人民币1180799元的涉案财产，依法予以没收，上缴国库；其他扣押的财物，由公安机关依法处置。

一审宣判后，李某等人提出上诉。

湖南省永州市中级人民法院同意一审法院的裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、关于组织、领导传销活动罪中组织、领导行为的认定

由于传销活动本质是一种层级性、金字塔式的诈骗活动，涉案人员多、等级复杂，传销组织中只有极少部分人员是受益者，其余绝大部分均是传销活动的受害者。因此，不能对所有传销人员均处以刑罚，而需要根据其在传销活动中的地位、作用，分别作出不同的裁决。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，对传销活动的组织者、领导者，应当依法追究其刑事责任。所谓传销活动的组织者、领导者，是指组织、领导传销组织的犯罪分子，是传销活动犯罪的首要分子；是在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。

根据相关法律及司法解释的规定，结合近年来的司法实践，笔者认为，对传销活动的组织、领导行为可以作如下理解。

1. “组织”行为。对本罪的组织者应当作限制解释，该罪与一般的集团犯罪不同，不处罚那些仅仅是传销的积极参加者，应当将组织者同积极参加者及

一般的参与人员区分开来。在传销组织中，其组织者是指策划、纠集他人实施传销犯罪的人，即那些在传销活动前期筹备和后期发展壮大中起主要作用，同时获取实际利益的骨干成员，除此之外的人不应当作为组织者加以处理，以免扩大打击面，不利于突出对首要分子的制裁力度。

2. “领导”行为，主要是指在传销组织中居于领导地位的人员，对传销组织的活动进行策划、决策、指挥、协调的行为，也包括一些幕后组织者对传销组织的实际操纵和控制行为。传销组织的领导者主要是指在传销组织的层级结构中居于最核心的，对传销组织的正常运转起关键作用的极少数成员。对领导者的身份，应当从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面综合认定。

基于上述分析，下列行为均属于组织、领导行为：为传销活动的前期筹备、初步实施、未来发展实施谋划、设计起到统领作用的行为；在传销初期，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为；在传销实施过程中，积极参与传销各方面的管理工作，如财务管理、讲课、鼓动、威逼利诱、胁迫他人加入行为。因而在本案中，被告人在传销活动前期筹备、传销初期、实施过程中，起到了组织领导作用，属于获取实际利益的骨干成员，其中，作为董事长、发起人、策划人的李某，副董事长、协助管理者谢某，财务人员王某认定为主犯，其他参与人员认定为从犯。

二、关于组织、领导传销活动罪名的具体认定

罪与非罪的认定，重点是要理顺和区分以下两个层面的关系。

一是传销与单层次直销的关系问题。单层次直销是商品和服务的生产者将生产的产品通过专卖店或者营销人员直接把产品销售给终端客户，且给予服务的销售方式，是一种合法且受法律保护的经营行为。它与传销具有本质的区别，主要表现在以下几个方面。

1. 是否以销售产品为企业营运的基础。直销以销售产品或者提供服务作为公司收益的来源。而传销则以拉人头牟利或者借销售伪劣或质次价高的产品变相拉人头牟利，有的传销甚至根本无销售产品可言。

2. 是否收取高额入门费。单层次直销企业的推销员无须缴付任何高额入门费,也不会被强制认购货品。而在传销中,参加者通过缴纳高额入门费或者被要求先认购一定数量质次价高(通常情况下价格严重高于产品价值)的产品以变相缴纳高额入门费作为参与的条件,进而刺激下线人员不择手段地拉人加入以赚取利润。

3. 是否拥有经营场所。单层次直销企业都有自己的经营场所,有自己的产品和服务,销售人员都直接与公司签订合同,其从业行为直接接受公司的规范与管理。而传销的“经营者”没有自己的经营场所,也没有从事销售产品或者提供服务的经营活动,只是假借“经营活动”骗取他人信任和逃避有关机关的管理和打击,通过收取高额入门费为整个传销组织的组织者和领导者攫取暴利,其本身不会产生任何的利润和收益,也不会为国家和社会创造任何的经济价值。

4. 是否遵循价值规律分配报酬。单层次直销企业的工作人员主要通过销售商品、提供服务获取利润,其薪酬的高低主要与工作人员的销售业绩相挂钩。而通过以高额回报为诱饵招揽人员从事“变相销售”的传销行为,因为其不存在销售行为,故不会产生任何的销售收入,其报酬全部来源于高额的会员费。更主要的是,并非所有传销人员都能够获取报酬,从整体上看,只有处于组织核心和顶层的领导者和组织者才能获取暴利,其余人员均是损失的承担者,不会获取任何收入。

5. 是否具有完善的售后服务保障制度。单层次直销企业作为正规经营的经济体,有合格、规范、快捷的售后服务操作流程,通常能够为顾客提供完善的退货保障。而传销活动绝大部分没有产品和服务,即便提供也通常强制约定不可退货或者退货条件非常苛刻。再者,传销组织一般也不会设立专门的售后服务部门,消费者已购的产品难以退货,遇到质量问题也得不到解决,消费者退货和投诉无门的情况普遍存在。

6. 是否实行制度化的人员管理。单层次直销形式下,企业对工作人员的管理模式正规、科学,有健全的工会组织,充分尊重人员的自由,保障员工的合法权益。而在传销组织中,上线主要通过非法拘禁、诱骗,甚至在某种情况下

采取非常暴力的手段控制下线，并以此对下线产生威慑进而使其继续发展下线，因而在传销活动中，传销人员尤其是处于底层的人员没有人身自由，合法权益难以得到保障。正因如此，传销活动往往诱发其他类型的犯罪，给正常的社会秩序和公民的生命财产安全带来严重影响。

二是区分传销行为与多层次直销行为(团体计酬)的罪名适用问题。从《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一关于“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的规定可以看出，组织、领导传销活动罪规制的是以“人头数”作为计酬标准的犯罪行为；而多层次直销的团体计酬方式则表现为上线以下线的销售业绩为依据计算报酬，而不是下线的人数。

这一显著区别一方面体现出以上两种行为的不同；另一方面也表明多层次直销行为不在对传销活动的刑罚打击范围之内。《中华人民共和国刑法修正案(七)》施行之后，对于团体计酬行为是否以非法经营罪定罪处罚，目前还存在争议。因此，司法实践中有必要将传销行为与多层次直销行为(团体计酬)区别开来。

本案中，被告人李某等人自2020年至案发期间，以某区块链平台钱包登录过系统的总数为442490个，通过实名认证的用户共计191035人。其中股东会员264个；蓝钻会员11972个；白金会员42384个；鼠宝宝会员1671个，资金流水数额高达9000万余元，属于“拉人头”计酬，明显区别于单层次直销的按销售计酬和多层次直销的团体计酬行为，符合组织、领导传销活动罪的构成特征，达到了追究刑事责任的标准。

编写人：湖南省蓝山县人民法院 晏斐斤

强奸罪共同犯罪中关于主观故意的认定

—— 吉某某等强奸案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院 (2023) 粤03刑终1267号刑事判决书

2. 案由：强奸罪

【基本案情】

案发前几天，包某通过某软件与同乡人吉某前结识后，二人相约2022年2月1日晚一起吃饭，吉某前邀请被告人沙某、吉某1、吉某某、吉某里一同前往，包某邀请了被害人热某、孙某、海某，五男四女在某市场附近一饭店吃饭。当晚饭后22时20分许，包某和海某先往某电子公司厂门口走，吉某1追往二人走的方向。后热某和孙某往也往厂门口方向走，沙某和吉某1跟随二人。在工厂附近，热某和孙某看到包某，三人遂一起往厂门口方向走。在厂门口沙某提议一同去娱乐场所唱歌，被热某等人拒绝，被害人热某因人脸识别问题未能进入厂内。

22时34分左右，吉某某、吉某1、沙某拉住被害人热某，未让其进入厂内。后吉某1、沙某强行控制被害人从厂门口拖拽至河边座椅处，吉某某跟随在后。吉某1、沙某、吉某某与被害人热某在长椅处停留5分钟左右。在此处被害人打了吉某1一巴掌，沙某提出强奸被害人，吉某1表示同意，吉某某未回答。热某挣脱并躲进附近的便利店里，三人跟随被害人进入便利店并拉扯热某，最后吉某1一人将热某拉出便利店。之后吉某1和沙某采用一人拉一边的

方式将热某再次拉往河边长椅处。23时35分许，被害人热某挣脱后再次迅速跑向厂门口，吉某1、沙某快速追上热某，采取一人抬上半身一人抬下半身的方式，将热某抬往龙华区观澜桂香社区燕鹏煤气供应站附近的河边草地上，沙某与吉某1二人轮流控制被害人，强行与被害人发生性关系，发生性关系期间被害人热某在生理期。其间，吉某某在离现场50多米处的长椅上。2022年2月2日0时许，在沙某第二次与热某发生性关系时，证人张某等人经过案发现场附近，沙某、吉某1见状迅速逃离现场。张某等向被害人热某询问情况后报警。被害人热某在案发现场看到吉某某，并对其进行质问，后吉某某逃离现场。

【案件焦点】

1. 原审被告人吉某某是否构成犯罪；2. 沙某、吉某1量刑是否不当，二人是否量刑应有所差别。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市龙华区人民法院经审理认为：吉某某既没有参与被告人沙某、吉某1强奸被害人的犯意谋划与联络，也没有实施强奸被害人的行为，亦不明知他人实施强奸行为而为其提供帮助或协助，因此，被告人吉某某既无犯意，亦无犯罪或帮助行为，其无需亦不应对被告人沙某、吉某1的强奸行为承担罪责。被告人沙某、吉某1无视国家法律，违背妇女意志，强行在公共场合轮流与被害人发生性关系，其行为均已构成强奸罪。被告人沙某、吉某1归案后能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。在本案的共同犯罪中，被告人沙某、吉某1均是主犯，被告人沙某系强奸的犯意提起者，并与被害人发生了两次性关系；被告人吉某1与被害人发生了一次性关系，对此，在量刑时予以区分。各被告人及其辩护人所提辩护意见中的合理部分，人民法院予以采纳。综上，根据被告人沙某、吉某1的犯罪事实、性质、情节以及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第三项、第四项、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第二项之规定，经原判审判委员会讨论决定，

判决如下：

- 一、被告人沙某犯强奸罪，判处有期徒刑十二年；
- 二、被告人吉某1犯强奸罪，判处有期徒刑十年；
- 三、被告人吉某某无罪。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：原审被告人沙某、吉某1无视国家法律，违背妇女意志，强行在公共场合轮流与被害人发生性关系，其行为均已构成强奸罪。二人在公共场所轮奸，应从重处罚。原审被告人吉某某既没有参与被告人沙某、吉某1强奸被害人的犯意谋划与联络，也没有实施强奸被害人的行为，亦不明知他人实施强奸行为而为其提供帮助或协助，因此，被告人吉某某既无犯意，亦无犯罪或帮助行为，其无需亦不应对被告人沙某、吉某1的强奸行为承担罪责。被告人沙某系强奸的犯意提起者，并与被害人发生了两次性关系，应从重处罚；被告人吉某1与被害人发生了一次性关系，对此，在量刑时对二主犯予以区分。广东省深圳市中级人民法院判决：

一、维持广东省深圳市龙华区人民法院(2022)粤0309刑初866号刑事判决第一项、第二项关于沙某、吉某1的定罪部分，撤销量刑部分，维持第三项吉某某的无罪判决；

- 二、被告人沙某犯强奸罪，判处有期徒刑十五年；
- 三、被告人吉某1犯强奸罪，判处有期徒刑十三年

【法官后语】

在本案的审理过程中，焦点问题是：一是原审被告人吉某某是否构成犯罪；二是沙某、吉某1量刑是否不当，二人是否量刑应有所差别。尤其是吉某某是否构成犯罪的问题，是最重要的焦点。

一、吉某某是否构成犯罪

犯意提出与意思联络是本案的关键之处，被告人沙某、吉某1明确供述并当庭确认强奸被害人的犯意系沙某与吉某1二人将被害人从便利店门口拉往河边方向的过程中提出的，被告人吉某某没有参与其中，且二人不知其去向。公诉人抛开犯意提起者被告人沙某对犯意提起供述的直接证据，和参与犯意联络

的被告人吉某1的犯意产生于吉某某在便利店拉被害人之后的供述，而以微信聊天记录相关内容等间接证据以及其对监控录像的解读来推定强奸犯意产生于吃饭前或在第一次工厂门口拉扯被害人时，据理不足，于法无据。

案发当晚，饭后沙某提议众人一起去娱乐场所唱歌，遭到女方拒绝后，随后拉扯女方，被害人热口伍牛因人脸识别问题未能进入工厂，吉某1、沙某上去拉被害人至河边座椅处，热口伍牛拒绝去娱乐场所唱歌并躲进便利店里，对此不仅有被告人沙某、吉某1等人稳定的供述，且与被害人热口伍牛案发后的陈述、证人的证言等相印证，已形成完整证明体系，足以认定，而非公诉人所主张的被告人从一开始拉被害人的目的就是要与被害人发生性关系，前往娱乐场所唱歌只是幌子，以唱歌之名行强奸之实，饭后的拉扯行为、便利店的拉扯行为和后面抬被害人、强奸被害人意图是一个连贯发展的过程，不能割裂开来看。本案中，强奸被害人的犯意产生于吉某1、沙某将被害人从便利店门口拉往河边方向的过程中，此过程被告人吉某某并未参与其中，强奸犯意产生于吉某某在便利店里拉被害人之后，吉某某与沙某、吉某1之间没有强奸被害人的犯意联络，其在便利店里拉被害人之时沙某、吉某1尚无强奸被害人的意图，其拉被害人仍为前面拉被害人去娱乐场所唱歌意图之延续，因此其不属于被告人沙某、吉某1强奸被害人之共犯。

被告人沙某、吉某1一致供述吉某某在便利店里拉了被害人之后便不知去向，二人没有指使吉某某为其望风，被告人吉某某稳定供述其没有为沙某、吉某1望风。在沙某、吉某1实施强奸行

为时，双方均不清楚对方具体在何处， 如何为另一方报信望风，事实上也是沙某、吉某1自行发现有路人经过，二人 遂停止强奸行为，落荒而逃，此时吉某某才看到从草丛中跑出来的沙某、吉某 1。因此，公诉机关指控被告人吉某某有望风行为，与查明的事实不符。

二、沙某、吉某1量刑是否不当，是否量刑应有所差别

对沙某和吉某1的焦点有两个： 一是原审被告人沙某、吉某1的量刑是否 不当；二是原审被告人沙某、吉某1是否量刑应有所差别。

1. 原审被告人沙某、吉某1的量刑不当，理由如下：原审认为被告人沙

某、吉某1具有如实供述、自愿认罪、初犯、有悔罪表现等情节，所以对二人可酌情从轻处罚。经查，第一，沙某刚到案时并未认罪，其称被害人自愿，系相约发生性关系等，后期供述是面对录像等铁证不得已而认罪，其虽然认自己的罪，但是对于同案犯吉某某的行为自始至终并未如实供述，所以不属于全案如实供述，也体现不出其悔罪之心；第二，本案性质恶劣，大年初一，虽非光天化日，但确是在公共场所，人来人往之河边道路上，没有任何树木遮挡，也没有草丛掩藏，从拉扯、跟随、守候、拖拽、控制、硬抬，强暴，2小时内暴力程度逐步升级，实属罕见，其主观恶性极深，依法应从重处罚；第三，本案被害人身心受损，财产受损。综上，本案无论从主观、客观和结果上都应从重处罚。原判属于量刑不当。

2. 原审被告人沙某、吉某1是否量刑应有所差别。原判认为，被告人沙某、吉某1均是主犯，被告人沙某系强奸的犯意提起者，并与被害人发生了两次性关系；被告人吉某1与被害人发生了一次性关系，对此，在量刑时予以区分。经查，第一，被告人沙某确系强奸的犯意提起者，其主观恶性更深；第二，客观行为上，沙某与被害人发生了两次性关系，吉某1与被害人发生了一次性关系；第三，沙某自始至终未能如实供述全案犯罪事实，而吉某1经过教育基本供述了犯罪事实。所以沙某的量刑应重于吉某1。检察机关抗诉认为不应区分沙某和吉某1量刑并不恰当。

对于吉某某罪与非罪的问题，经过证据缜密分析，按照存疑有利于嫌疑人的原则，对吉某某判处无罪。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 王晓磊

二、刑罚的具体运用

(一) 量刑

31

年满七十五周岁老年人故意杀人

“特别残忍手段”的把握认定

—— 丁某故意杀人案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省泰州市中级人民法院(2023)苏12刑初3号刑事判决书

2. 案由：故意杀人罪

【基本案情】

被告人丁某(案发时七十九周岁)因夫妻关系长期不和而与其妻朱某(殁年八十二周岁)积怨,曾产生与朱某同归于尽的念头。2022年6月1日上午,丁某与朱某因琐事再次发生争吵,对此怀恨在心。次日15时许,丁某在其家院内,手持不锈钢菜刀和不锈钢水果刀各一把,对被害人朱某头面部及双上肢等部位连续用力砍击,致朱某倒地后又持续用力砍击,直至被闻讯赶到现场的邻

居喝止。朱某经送医院抢救无效死亡。经鉴定，被害人朱某符合被他人用长刃锐器反复砍、切头面部、双上肢致失血性休克合并蛛网膜下腔出血死亡。被告人丁某作案后自杀未遂，归案后如实供述自己的罪行。

【案件焦点】

对于犯罪时年满七十五周岁的丁某如何量刑，其故意杀人手段是否属于“特别残忍”。

【法院裁判要旨】

江苏省泰州市中级人民法院经审理认为：被告人丁某故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为构成故意杀人罪，且犯罪情节恶劣，犯罪后果严重，依法应予惩处。被告人丁某犯罪以后如实供述自己的罪行，属坦白，依法对其从轻处罚。被告人丁某犯罪时已满七十五周岁，依法可以从轻处罚，对其不适用死刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第三款、第十七条之一、第四十九条第二款、第五十七条第一款、第六十四条之规定，作出如下判决：

一、被告人丁某犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；

二、作案工具菜刀及水果刀各一把，予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案在对已满七十五周岁的被告人丁某故意杀人如何准确量刑产生两种观点：

第一种观点认为，被告人丁某持双刀持续猛击被害人头面部和双上肢，致其妻朱某头面部被砍至血肉模糊，共计六十多处创伤，手段特别残忍，虽然审判时丁某已年满七十五周岁，但依法应当适用死刑。

第二种观点认为，被告人丁某审判时候已满七十五周岁，不适用死刑，充分考虑犯罪的具体事实、起因、情节综合认定，其杀人手段并不属于特别残忍。

本案采纳第二种观点。具体理由如下。

1. 对年满七十五周岁的人犯罪在量刑时，应当准确把握刑法对犯罪年龄与量刑的特殊规定和立法本意，充分考虑老年人个体的特殊情况。《中华人民共和国刑法》第十七条之一规定，已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚，而2011年颁布的《中华人民共和国刑法修正案(八)》中增加一款为《中华人民共和国刑法》第四十九条第二款的规定，即“审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外”。要注意把握“特别残忍手段”的认定，应当走出“凡是杀了人，手段必然特别残忍”的思维定式，综合考虑案发起因、使用的凶器、事发经过持续状态、打击的方式和力度以及老年人自身的心理和生理状态，结合具体案情综合判断。

2. “特别残忍手段”在司法适用中并无明确的列举，在个案具体判断时应当结合已满七十五周岁的老年人年龄本身以及该法条规定的内涵进行综合分析，不适用死刑既包括不适用死刑立即执行也不适用死刑缓期二年执行。“特别残忍手段”的故意杀人结合具体的司法实践，一般应当包括以造成被害人严重肢体残缺或人体机能丧失而采用极端肉刑折磨，故意延长被害人的痛苦时间，给被害人带来巨大的精神痛苦，手段严重挑战社会一般民众心中对善良风俗、伦理底线、人类恻隐之心的底线。本案中，丁某使用双刀数十次连续砍击被害人朱某头面部在尸检报告照片中的显示确实给人难以忍受的残暴观感，但是考虑事发突然性以及因双方多年夫妻矛盾激化情感积怨导致的累积因素，加之被告人丁某选择的作案工具来自家用的水果刀和菜刀，且在作案后自杀未遂的心态情绪，自身亦已届八十周岁的老人身体机能等情况，结合具体案件事实综合分析，应当审慎把握评价“特别残忍手段”而判处死刑的适用，不宜认定被告人丁某手段特别残忍，对其不适用死刑。

3. 本案中，丁某故意杀人致人死亡，犯罪情节恶劣、后果严重，但因其犯罪时已年满七十五周岁、有坦白情节，结合本案具体事实，依法可以从轻处罚，不再对其适用死刑或者死缓。

一审宣判后发现前罪尚有未执行完毕的 剥夺政治权利的刑期应当如何计算

—— 潘某交通肇事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省泰州市中级人民法院(2023)苏12刑终58号刑事判决书

2. 案由：交通肇事罪

【基本案情】

2004年1月15日被告人潘某因犯抢劫罪、强奸罪被人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币3万元。其在服刑期间，因确有悔改表现被减刑七次，刑期减至2020年5月1日，附加剥夺政治权利四年。2022年9月1日19时50分左右，被告人潘某驾驶重型低平板半挂车，沿京沪高速公路上海方向行驶至泰州市境内，违法跨实线变更车道，所驾车辆与正常行驶的小型轿车相撞，致小型轿车内驾驶员陈某及乘客谭某当场死亡、两车受损。经交警部门认定，潘某负此事故的全部责任。因涉嫌交通肇事罪，被告人潘某2022年10月13日被取保候审，2023年4月3日被逮捕。

【案件焦点】

一审宣判后发现前罪尚有未执行完毕的剥夺政治权利刑期如何计算。

【法院裁判要旨】

江苏省泰州市高港区人民法院经审理认为：被告人潘某的行为已构成交通

肇事罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，以犯交通肇事罪判处被告人潘某有期徒刑三年六个月。

一审宣判后，公诉机关江苏省泰州市高港区人民检察院提起抗诉，认为被告人潘某前罪尚有未执行完毕的附加剥夺政治权利，原审判决未对其依法数罪并罚，系适用法律错误。江苏省泰州市人民检察院支持抗诉。

江苏省泰州市中级人民法院经审理认为：原审被告人潘某刑满释放后开始执行的附加刑剥夺政治权利四年，期满应至2024年4月30日，其间因涉嫌交通肇事罪被取保候审，并在原审宣判后于2023年4月3日被逮捕，属于在执行附加剥夺政治权利期间又犯新罪，其剩余的一年零二十七天附加剥夺政治权利尚未执行完毕，依法应与新犯交通肇事罪数罪并罚。对抗诉意见予以采纳，原判认定的交通肇事罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，唯对原审被告人潘某前罪尚未执行完毕的附加剥夺政治权利未与其所犯交通肇事罪实行数罪并罚不当，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项、第十五条，《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十一条、第六十九条、第五十八条第一款之规定，作出如下判决：

一、撤销江苏省泰州市高港区人民法院(2023)苏1203刑初8号刑事判决；

二、原审被告人潘某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年六个月，与前罪尚未执行完毕的附加剥夺政治权利一年零二十七日并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，剥夺政治权利一年零二十七日。

【法官后语】

本案被告人潘某涉嫌交通肇事罪于2022年10月13日被取保候审，一审宣判时间为2023年3月22日，原审法院决定对潘某逮捕的时间为2023年4月3日。后因宣判后原审检察机关发现潘某前罪尚有未被执行完毕的剥夺政治权利刑期遂抗诉。本案争议焦点在于：一审宣判后发现被告人前罪尚有未执行完毕

